

1528632-74.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/11/2022

... O Leonardo foi preso em flagrante em razão de outro roubo. Como era uma quadrilha que praticava roubos com este "modus operandi" a vítima do roubo aqui apurado foi chamada, chamaram a vítima em delegacia. Mas não se recorda do reconhecimento porque está confundindo o Leonardo com outras investigações em que figura como suspeito. Passou alguns dias do roubo até o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528632-74.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528632-74.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2234324/2021 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 14332089 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2255/21/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2234324 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

5 INDIVÍDUOS DESCONHECIDOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

VISTOS.

MARCOS MATHEUS SANTOS FRANÇA, qualificado nos autos (página. 19), e LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA, qualificado nos autos (página 47), foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 69 do CP, porque, segundo narra a denúncia, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 11h00min, na Rua Vinte e Cinco de Março, esquina com a Rua Paula Sousa, Sé, nesta cidade e comarca de São Paulo, os Denunciados agindo em concurso entre si e com o adolescente Kauê Torres de Souza, e mais dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pela simulação de portar arma de fogo, diversos produtos de tabacaria tais como carvão, tabaco, isqueiros e maços de cigarros, avaliados em R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), todos de propriedade da empresa Mundial Comércio de Produtos de Tabacaria, representada por Miquéias Fábio de Lima Andrade. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que nas mesmas condições de tempo e local, MARCOS MATHEUS SANTOS FRANÇA e LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA corromperam ou facilitaram a corrupção do menor de 18 anos, Kauê Torres de Souza, com eles praticando o roubo acima citado.

Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, a vítima Miquéias Fábio tentava realizar a entrega de produtos diversos de tabacaria da empresa Mundial Comércio,

da qual é funcionário. Entretanto, os denunciados Marcos e Leonardo, juntamente com o auxílio do adolescente Kaue Torres e mais dois indivíduos não identificados, abordaram a vítima Miquéias e, mediante a simulação de portarem arma de fogo, determinaram que entregasse o carrinho contendo todos os produtos.

Nesse momento, a vítima, temerosa por sua vida, entregou o carrinho aos denunciados e saiu em direção à loja. Após, os denunciados, o adolescente Kaue e os dois comparsas se evadiram do local na posse dos produtos.

Posteriormente, a vítima Miquéias reconheceu positivamente os denunciados como autores do roubo (fls. 13 e 40). Consta que os denunciados também são investigados por fatos análogos nos autos do inquérito policial 1520668-78.2021.8.26.0228, ocasião em que se utilizaram do mesmo modus operandi para a subtração de bens da vítima Amauri Amaro da Silva (fls. 29).

Interrogados, MARCOS e LEONARDO negaram a prática do roubo (páginas 20 e 48).

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2021, em decisão de págs. 168/173, em que foi previamente agendada data para realização de eventual audiência concentrada.

Foram apresentadas respostas à acusação, em favor do acusado Marcos, por meio de advogado constituído, às págs. 182/199, e em favor do acusado Leonardo, também por meio de advogado constituído, às págs. 234/244.

Ausentes hipóteses de rejeição da denúncia ou absolvição sumária, foram afastadas as teses defensivas e ratificado o recebimento da denúncia e a necessidade de instrução processual (págs. 213/214 e 263/265). As defesas requereram a revogação da prisão preventiva dos acusados, o que foi indeferido por este Juízo.

Em audiência realizada em 1º de dezembro de 2021 (págs. 262/270), os réus foram, preliminarmente, citados, sendo iniciada então a colheita da prova oral, consistente na oitiva da vítima Ali e das testemunhas policiais Emerson e Eduardo.

Diante da insistência do Ministério Público na oitiva da vítima Miquéias, foi designada audiência de instrução em continuidade para o dia 23 de fevereiro de 2022, que não se realizou, tendo em vista que não houve retorno dos eventuais endereços pesquisados pelo Ministério Público. Na oportunidade, a pedido das defesas, foi revogada a prisão preventiva dos acusados, conforme págs. 338/340.

Em nova audiência, realizada em 23 de março de 2022, preliminarmente, em razão da renúncia da defensora constituída do acusado Leonardo, foi a seu pedido nomeado Defensor Público para exercer sua defesa. Considerando que novamente não foram juntados tempestivamente eventuais endereços onde a vítima possa ser localizada, foi designada nova data para sua oitiva.

Contudo, em audiência realizada em 17 de maio de 2022, novamente não sendo localizada a vítima, o Ministério Público desistiu de sua oitiva, o que foi homologado pelo Juízo. Foram realizados então os interrogatórios dos réus. As partes formularam ainda requerimentos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (págs. 429/431).

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi declarada encerrada a instrução probatória, passando-se aos debates através de memoriais.

O Ministério Público apresentou memoriais às págs. 452/456 pugnando, em síntese, pela total procedência da ação penal. Sustenta que a materialidade restou comprovada conforme boletim de ocorrência pelo auto de reconhecimento de pessoa e pelos depoimentos colhidos em juízo. Afirma ainda que a autoria também é incontestada, diante das declarações das testemunhas e do reconhecimento pela vítima.

Aduz que o reconhecimento efetuado pela vítima em fase policial, pese não tenha sido reproduzido em Juízo, é corroborado pelos depoimentos policiais colhidos em sede judicial, atestando que os réus já eram investigados por roubos cometidos com o mesmo modus operandi. Argumenta, ainda, que o delito de corrupção de menores também restou comprovado pela prova oral colhida em Juízo e pelo reconhecimento efetuado pela vítima em solo policial. Por fim, fez ponderações acerca da dosimetria das penas.

A d. Defesa do acusado Marcos apresentou memoriais (págs. 462/474), pleiteando a absolvição, argumentando, em síntese, que a vítima Ali não possuía notas fiscais dos produtos supostamente subtraídos, tornando impossível saber sua origem e real proprietário ou se, de fato, realmente existem, ressaltando suspeita sobre o que o

fato de que o suposto dono das mercadorias não foi à delegacia na data dos fatos e nem sabe do paradeiro de seu funcionário. Aduz, ainda, que o reconhecimento policial já fora duvidoso em razão da própria vítima ter declarado em delegacia que os autores do roubo utilizavam máscara descartáveis brancas o que dificultou a identificação de sinais característicos dos rostos.

Sustenta que em razão de Marcos e do adolescente reconhecido Kauê terem porte físico idêntico, houve confusão por parte da vítima no reconhecimento do acusado, que é a única prova colhida em desfavor do réu, ressaltando-se que os policiais ouvidos em Juízo não puderam prestar esclarecimentos sobre como ocorreu o procedimento porque não se recordavam.

Postula, diante destes argumentos a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de furto, diante da ausência de esclarecimentos da vítima sobre o modus operandi empregado para a subtração. Fez pedidos atinentes à dosimetria e direito de recurso em liberdade caso sobrevenha édito condenatório. Por fim, a Defensoria Pública apresentou memoriais em favor do acusado Leonardo (páginas 490/494), pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Argumenta que o dono das mercadorias nada acrescentou com relação a autoria por não ter presenciado os fatos. Os policiais ouvidos em Juízo, por sua vez, pouco disseram efetivamente sobre a participação do acusado Leandro no delito, sequer se lembrando como teriam sido as circunstâncias de seu reconhecimento pessoal pela vítima. Com relação ao reconhecimento realizado em sede policial, aduz que ocorreu mais de uma semana após o delito ao arrepio das normas processuais, feito sem a ampla defesa e contraditório, não se sabendo como efetivamente foi feito, não havendo indicação de que o acusado o adolescente Kauê foram colocados com outras pessoas. Acrescenta que nenhum objeto material do crime foi encontrado em sua posse, sendo que a versão do acusado deve ser considerada elemento probatório, sobretudo porque não refutada cabalmente pelas provas dos autos.

Em relação ao crime de corrupção de menores, aduz que a acusação não trouxe aos autos prova de que o acusado tivesse ciência da real idade do adolescente, nem a comprovação de que o adolescente possuía caráter ilibado e conduta irrepreensível, razão pela qual é de rigor a absolvição por insuficiência probatória. Formulou ainda pedidos subsidiários referentes à dosimetria penal e ao direito de recuso em liberdade.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Do percuciente exame do frágil e conflitante quadro probatório produzido no contraditório judicial, infere-se que não há prova segura e cabal da autoria do crime de roubo pelos acusados. De fato, ao término da instrução criminal, verifica-se que persiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Sempre importante lembrar que a dúvida milita a favor do réu, em vista do consagrado princípio do “in dubio pro reo”, bem como em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, pese a existência de alguns elementos indiciários contra os acusados, que inclusive justificaram o recebimento da denúncia, tais indícios não são veementes, nem foram confirmados em juízo através de elementos probatórios seguros e conclusivos, aptos a comprovar cabalmente a autoria delitiva.

É certo que uma condenação criminal somente pode ocorrer quando apoiada em provas seguras, cabais e extensas de dúvidas, sendo que indícios isolados ou meras presunções, isoladamente consideradas, não constituem prova dotada dessas qualidades, sendo insuficientes para amparar um decreto condenatório.

Ademais, os indícios que autorizam um juízo condenatório são apenas os concludentes e que conduzam a certeza e afastem qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 218:96, RT 166:553). Isto porque o Direito Penal não opera conjecturas ou presunções, exigindo prova segura e indubitável da autoria delitiva.

Feitas tais considerações, no caso, verifica-se que apesar dos reconhecimentos pessoais efetuados pela vítima em sede policial, permanece séria dúvida no tocante à autoria do crime de roubo.

Na fase policial, os réus negaram a prática delitiva e disseram que provavelmente foram confundidos com outros vendedores e "puxadores" da Rua 25 de março. Interrogados em juízo, voltaram a negar, veementemente, a prática delitiva. Em seu interrogatório judicial, o acusado MARCOS MATHEUS SANTOS FRANÇA narrou que trabalha na rua 25 de março com produtos eletrônicos, foi pego com oito celulares, não reconhece nenhum dos nomes citados pelo Juiz, nem Kaue e nem Leonardo. A polícia o pegou perguntando "cade a mercadoria" e nisso foi ajudar um rapaz que deu 200 reais pela ajuda, rapaz chamado Rodrigo. Ajudar a descarregar uma carga. Após isso a polícia apareceu com uma foto dele dizendo que ele tinha roubado produtos de tabacaria. A carga que descarregou para o Rodrigo não tem nada a ver com a carga roubada da tabacaria. Os policiais os pegaram na rua 25 de março, na esquina em que ele fica. Nega envolvimento no crime. Diz que o policial chegou o abordando e questionando sobre os produtos da tabacaria e se o acusado conhecia os demais indivíduos citados. Foi preso com oito celulares, esses oito celulares são de clientes e pediu para o advogado retirar os celulares apreendidos. Não foi levado a delegacia para fazer reconhecimento pessoal. Os policiais tiraram foto dele, os policiais o bateram e o forçaram a falar coisas que ele não sabia. Na rua 25 de março ele conhece bastante gente, arruma os celulares de bastante pessoas. Os policiais o ameaçaram dizendo que se ele não falasse iam jogar droga e bater nele. Ele é evangélico e diz não querer mexer com essas coisas. Reforça que foi levado para delegacia, mas não fizeram reconhecimento pessoal. Nunca foi processado. Consertou o celular do Rodrigo. Acusaram com uma coisa, sendo que ele só mexe com celular, queria falar referente os oitos aparelhos que apreenderam na delegacia. O Rodrigo não está preso. Matheus continua trabalhando com celular e nunca foi acusado por qualquer outro crime. No dia e na hora do crime ele estava na rua 25 de março, tem 23 anos realiza o conserto de celulares e também vende roupa, estudou até o 1º colegial, solteiro e sem filhos, reside no barro branco, na cidade tiradentes, rua Ricardo da costa 249, mora lá desde pequeno e nunca foi chamado para ir na delegacia fazer reconhecimento pessoal. Não tem nada contra o dono da tabacaria e nem contra os policiais. Tem uma loja no Instagram, compra tela de celular e faz o conserto. Conserta os celulares na loja de um amigo paraguaio. Quando tem conserto ele vai até a loja do amigo paraguaio e também compra roupa e vende na rua 25 de março. Não conhece o acusado preso e também nunca foi preso. Por sua vez, o réu LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA, em seu interrogatório judicial, disse que não participou do assalto, não estava no centro de São Paulo esse horário, mora em Poá, trabalhava no centro como puxador nas lojas, era motorista de aplicativo, mas com a pandemia e as dificuldades perdeu seu carro. Sua mulher estava grávida de 5 meses, na época, e fazia home office, tem uma filha de três anos. Foi para o centro de São Paulo fazer bico, no dia do assalto estava tendo greve no trem e tem conversa com a esposa que ele foi de aplicativo da estação de Poá até Guaianases por volta das 10:30 e 11:00, até chegar no centro de São Paulo, onde fazia bico para ajudar a esposa. Não estava presente na hora do roubo. Teve passagem por assalto em 2013, foi réu confesso, saiu em 2018 e aprendeu com os erros. Foi para delegacia, os policiais viram que ele já tinha uma passagem e foi colocado em uma sala, dizendo que a vítima o tinha reconhecido, assim foi preso. Os rapazes que foram presos junto com Leonardo disseram que ele não estava junto no assalto e ele está sendo julgado por esse crime também. Foi condenado por um crime semelhante a 5 anos e 7 meses, não confessou. Não conhece o Marcos Matheus, nem o menos Kaue, conhece apenas o Rodrigo, o qual estava sendo investigado pelo roubo da tabacaria. Foi na delegacia que o conheceu e estão presos juntos. Infelizmente ele está sendo acusado de um crime que não cometeu, tem uma filha de 3 anos e outra de 4 meses, que ainda não conhece. Tem 35 anos, trabalhava como motorista de aplicativo, tinha financiado um carro no nome da esposa, porém perdeu devido a pandemia e aí começou a fazer os bicos de puxador no centro de São Paulo. Tem o 2º grau completo, seu estado civil em união estável, duas filhas, uma de 3 anos e outra de 4 meses, está preso pelo assalto que estava o Rodrigo, Lázaro e o menor Kaue. Já foi a audiência e foi condenado, pediu para o defensor recorrer, o julgamento foi dia 28 de fevereiro de 2022. Além desse julgado, teve uma condenação anterior, cumpriu a pena. Não conhecia nem as vítimas nem os acusados. Na delegacia

colocaram ele e mais os três rapazes para fazer o reconhecimento pessoal. Foi uma única vez na delegacia fazer reconhecimento, não falaram que ele foi reconhecido por foto. Disseram que quem tava reconhecendo era a vítima do suposto assalto que os demais estavam sendo acusados e não do crime do roubo da tabacaria.

Os acusados negaram, portanto, de forma incisiva, o envolvimento no roubo descrito na denúncia. Ao acusado está garantido o direito ao silêncio, bem como o de não produzir provas contra si, incumbindo, portanto, ao Estado a tarefa de comprovar a autoria e materialidade do delito, observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

As negativas de autoria e as versões escusatórias apresentadas pelos réus são plausíveis e não foram infirmadas por provas consistentes produzidas no contraditório judicial

Frise-se que a vítima não foi localizada para ser ouvida em sede judicial e realizar o reconhecimento pessoal segundo os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o crivo do contraditório. Foram ouvidos apenas o dono das mercadorias, que pouco pôde acrescentar sobre os fatos, não tendo visualizado os réus em sede policial e não se recordando nem mesmo se os produtos subtraídos tinham nota fiscal.

A vítima ALI MOHAMAD JEBABI narrou em Juízo que não estava presente no momento do roubo. Tem câmeras mas o roubo não ocorreu no estabelecimento e sim na rua. Abordaram o funcionário que estava com as mercadorias na rua. Os policiais preferiram que não tivesse contato com os réus em delegacia. É seu ex funcionário. Tentou contato com ele mas não teve retorno. A mercadoria não foi recuperada. Sabe que seu funcionário reconheceu dois indivíduos na delegacia. Ele falou que simularam o assalto com uma bolsinha colocando a mão dentro dela simulando estarem armados o que o amedrontou. Teve prejuízo de oito mil e quinhentos reais. Não se recorda o dia que ocorreu o roubo nem quando foi registrada a ocorrência, mas foi no segundo semestre deste ano. Não se recorda qual dia registrou a ocorrência, mas foi pouco tempo depois do roubo. Na mesma hora o funcionário veio, comunicou que foi roubado e descreveu como ocorreu. Acredita que ele tenha narrado que foi abordado por quatro indivíduos. Costuma ter notas fiscais dos produtos, mas não se recorda da nota destes. Não se recorda se os réus já estavam presos quando foi na delegacia. Foi em delegacia, mas não teve contato com os réus, eles estavam embaixo e ficou na sala de cima. Estavam lá para reconhecimento, mas não sabe se por este fato.

Por outro lado, os depoimentos policiais em Juízo são deveras vagos e imprecisos, indicando que o fato de estarem realizando outras investigações envolvendo roubos com semelhante "modus operandi" na região pode ter causado certa confusão nos depoimentos, tornando temerário considerá-los, isoladamente, prova cabal para prolação de édito condenatório, mormente considerando que vítima não foi localizada para proceder ao reconhecimento pessoal e depor em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Em seu depoimento judicial, o policial civil EMERSON ROCHA DOS SANTOS disse que tomaram conhecimento do roubo e a vítima na hora reconheceu o Marcos fotograficamente em um primeiro momento. Depois, em diligências, chegou a informação de que o Marcos estava na 25 de março. Localizaram o suspeito, pediram a prisão temporária e conduziram à delegacia onde a vítima efetuou o reconhecimento pessoal perfilado com outras pessoas do lado dele. É o que está sem máscara de camiseta bege no CDP Pinheiros. A vítima descreveu que ele estava andando com o carrinho de entregas e foi abordado na rua por cinco indivíduos. Primeiro dois indivíduos magros que exigiram o carrinho, ignorou e seguiu, então apareceu um rapaz mais forte simulando estar armado e entregou os bens e foi embora. O Leonardo foi preso em flagrante em razão de outro roubo. Como era uma quadrilha que praticava roubos com este "modus operandi" a vítima do roubo aqui apurado foi chamada, chamaram a vítima em delegacia. Mas não se recorda do reconhecimento porque está confundindo o Leonardo com outras investigações em que figura como suspeito. Passou alguns dias do roubo até o registro da ocorrência, não se recorda se a vítima descreveu as características dos roubadores

Por sua vez, o policial civil EDUARDO KEITH HIROSE narrou em juízo que participou

das investigações relacionadas a este caso com seu parceiro. Com as características de Marcos, que é muito grande e forte, efetuaram condução à delegacia e chamaram a vítima para efetuar o reconhecimento pessoal, que resultou positivo, tendo pedido sua prisão temporária. Dias depois foi preso em flagrante o restante da quadrilha. O Marcos é o que está de bege e sem máscara. O Marcos foi reconhecido primeiro por foto, mas no mesmo dia foi localizado e posteriormente reconhecido pessoalmente. Foram presos posteriormente três indivíduos maiores e um menor em flagrante de crime praticado com o mesmo modus operandi. Não se recorda se a vítima da tabacaria foi em delegacia reconhecer o acusado Leonardo, dentre esses indivíduos presos. Não participou do interrogatório policial dos réus. Tinham fotografia do Marcos, no cadastro como averiguado e mostraram à vítima. No reconhecimento pessoal foram perfilados outros indivíduos. A vítima foi segura em reconhecer o Marcos pessoalmente. Não se recorda se a vítima retornou em delegacia para fazer o reconhecimento do Leonardo, mas acredita que sim. Efetuiu a prisão em flagrante do Leonardo. Quando efetuaram a prisão em flagrante do Leonardo e demais indivíduos ficaram sabendo que faziam parte da mesma quadrilha com o Marcos. Apenas o Leonardo e o Marcos foram reconhecido pela vítima da tabacaria. O menor também foi reconhecido pela vítima. Não se recorda se a vítima relatou as vestimentas dos roubadores. Recorda-se que reconheceu o menor porque o mesmo é bem alto e magro. Há de se consignar que existem algumas inconsistências e omissões nos depoimentos policiais. O próprio policial Emerson narrou que não se recordava do reconhecimento de Leonardo porque poderia estar se confundindo com outras investigações em que ele é suspeito.

Afirmou ainda que no reconhecimento policial, Marcos foi perfilado ao lado de outros suspeitos, informação que não consta do auto de reconhecimento pessoal de p. 13. Nenhum dos dois policiais ouvidos se recordou do reconhecimento pessoal do acusado Leonardo.

Recordaram-se apenas que a vítima reconheceu Marcos, sem sombra de dúvidas. Contudo, relevante assinalar que a defesa sustenta possível confusão da vítima no reconhecimento de Marcos pelo fato de ter porte físico semelhante ao do menor Kauê, que também foi por ela reconhecido (p. 40), sendo certo que os reconhecimentos foram efetuados em momentos distintos. Aliás, os reconhecimentos foram todos realizados dias depois dos fatos, em razão da ocorrência ter sido registrada apenas três dias depois.

Vale ressaltar que nenhum bem da vítima foi apreendido em posse dos acusados. Em que pese o fato de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma importância, entendo que, neste caso, seu depoimento policial não tem o condão de, isoladamente, embasar decreto condenatório. Mesmo porque, como pode se observar do depoimento policial à p. 07, a vítima relatou que "todos utilizavam máscara descartável branca, o que dificultou a identificação de sinais característicos do rosto". Ademais, relatou que não sabia "mais detalhes de identificação dos indivíduos, devido à rapidez da ação".

Acrescenta-se que a vítima relatou ter sido abordada por cinco roubadores, dando-se a ação com rapidez, em rua movimentada, o que por certo dificulta o reconhecimento. Portanto, diante desses fatores, seria essencial trazer a vítima a Juízo para que, sob o crivo do contraditório, reconhecesse os acusados segundo os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, explicasse as circunstâncias em que se deram os fatos e os reconhecimentos realizados em sede policial, especialmente o grau de certeza e quais características físicas o fizeram reconhecer os acusados dos momentos dos fatos.

De outra banda, poderia se prestar mais segurança ao reconhecimento efetuado em sede policial caso tivesse sido realizado logo após os fatos, podendo a vítima reconhecer as vestes dos roubadores, conforme as descreveu em seu depoimento policial, contudo, isso não foi possível, em razão da ocorrência ter sido registrada apenas três dias depois, sem justificativa aparente.

Inegável, ainda, que diante de todas estas dificuldades e do lapso temporal decorrido entre os fatos e o momento dos depoimentos em juízo, o processo mnemônico fique mais suscetível a pequenas falhas, o que não significa, necessariamente, que a vítima tenha mentido em delegacia. Contudo, à míngua de outras provas que apontem

a autoria delitiva, a insegurança no depoimento da vítima suscita dúvida razoável quanto à participação dos réus no evento criminoso.

Não se ignora que em casos de crime contra o patrimônio, cometidos com o emprego de grave ameaça e as escondidas, a palavra da vítima tem valor determinante, entendimento que adoto. Todavia, isoladamente ela não basta para um decreto condenatório, devendo ser corroborada pelas demais provas carreadas aos autos, o que não se verifica no caso vertente.

Ademais, importante ressaltar que a prova colhida indica que inicialmente foi mostrada fotografia, apenas dos réus Marcos, em um contexto em que a vítima provavelmente estava ciente de que ele era investigado por outros delitos da região, sendo-lhe então apresentada a foto de p. 11, tirada em delegacia. Não se pode, portanto, descartar possível indução no reconhecimento pessoal, que, de acordo com o auto de p. 13, foi assim como o reconhecimento fotográfico, realizado à revelia das recomendações do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ainda com relação ao reconhecimento do acusado Marcos, vale reprimir a alegação defensiva, não infirmada pela prova dos autos, de que o acusado possui porte físico semelhante com Kauê, adolescente reconhecido posteriormente, sendo conveniente rememorar que a vítima relatou estarem os roubadores em cinco indivíduos, todos mascarados.

Tal circunstância o que certamente dificulta o reconhecimento com base em traços de fisionomia, sendo bem possível que tenha reconhecido o acusado pelo porte físico. É certo ainda que tais circunstâncias não puderam ser esclarecidas em razão da vítima não ter sido mais localizada pela Justiça.

Já em relação ao acusado Leonardo, o reconhecimento pessoal foi realizado vários dias depois do reconhecimento do acusado Marcos, que já havia sido efetuado dias após os fatos. Os policiais relataram que o acusado havia sido preso em flagrante por outro delito e então convidaram a vítima a comparecer em sede policial, onde Leonardo foi submetido a procedimento de reconhecimento, ao lado do menor Kauê, que também foi reconhecido na oportunidade, novamente sem que fossem perfilados outros indivíduos ao lado dos investigados, como preleciona o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Deste modo, não se pode conferir valor absoluto aos reconhecimentos pessoais realizados exclusivamente na fase policial pela vítima dias após os fatos, pois este pode gerar erros, decorrentes do abalo emocional e, o mais frequente, a semelhança entre as pessoas.

Não se pode ainda descartar a hipótese da vítima ter sido autossugestionada ou influenciada psicologicamente, por estar abalada emocionalmente e traumatizada, vindo a reconhecer de imediato aqueles indivíduos que lhe foram exibidos e apontados pelos policiais como suspeitos da prática de roubos com semelhante modus operandi na região.

Ulpiano, doutrinador romano, duzentos anos antes de Cristo, lecionava que é preferível absolver um culpado do que condenar um inocente ('nocentem absolvere satius est quam innocentem damnari'). É lógico que o ideal é absolver todos os inocentes e condenar todos os culpados, mas a pretensão fica ao largo da falibilidade humana. Enquanto operadores do direito, devemos buscar compreender que se não há prova segura contra alguém, não pode existir uma condenação penal. É um ato de responsabilidade do Juiz absolver um Réu nessas condições.

De fato, o isolado depoimento policial da vítima, assim como o reconhecimento pessoal à revelia das recomendações do artigo 226 do Código de Processo Penal, evidenciam a fragilidade da prova, sendo insuficiente a ensejar certeza possível a fundamentar um pronunciamento condenatório.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA. É certo que a palavra da vítima é de extrema importância, sendo apta a ensejar um juízo condenatório, desde que em consonância com os demais elementos de convicção carreados no caderno processual. Destarte, restando isolada a versão apresentada pelo ofendido, e mostrando-se inapta a extirpar a possível inocência do réu, a absolvição é medida que se impõe. (TJ-MG – Apelação Criminal

APR 10313140088490001 MG (TJ-MG) - 3ª Câmara Criminal - data da publicação:

07/06/2017) negritei

Apelação Criminal, Roubo e estupro. Objetiva a absolvição diante da fragilidade da prova. Condenação escorada apenas no reconhecimento pessoal feito pela vítima. Nada mais há nos autos a corroborar a versão acusatória. Insegura a prova que sustentou decreto condenatório. Aplicação do 'in dubio pro reo'. Provido o apelo para absolver o réu com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (TJ-SP- Apelação Criminal 0007236-47.2002.8.26.0191 - 1ª Câmara de Direito Criminal - Relator Péricles Piza - data do registro: 01/02/2007) negritei

Posto isto, torna-se imperiosa a absolvição, vigorando na hipótese os princípios "in dubio pro reo" e da presunção de inocência.

Neste aspecto, vale lembrar: "Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ap. 126.465, TACrimSP, Rel. Geraldo Ferrari).

Assim sendo, e atento aos princípios basilares do processo penal, é de se ressaltar que a prova da autoria cabia à acusação, que, como dito alhures, não conseguiu cumprir sua função a contento, especialmente pelo fato do paradeiro da vítima ter restado desconhecido à Justiça Criminal, produzindo prova insipiente e duvidosa, não sendo estreme de dúvidas, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do "in dubio pro reo".

Enfim, a prova produzida no contraditório judicial é frágil e inconcludente e não permite um juízo de certeza a respeito da autoria e participação dos réus no evento criminoso.

Sobre o tema do ônus da prova, leciona Fernando Capez: "A prova é indubitavelmente um ônus processual, na medida em que as partes provam em seu benefício, visando dar ao juiz os meios próprios e idôneos para formar a sua convicção. Ônus da prova é, pois, o encargo que têm os litigantes de provar, pelos meios admissíveis, a verdade dos fatos. (...) Portanto, cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas." (Curso de Processo Penal, 6. ed - São Paulo: Saraiva, 2001, p. 249).

Importante ressaltar ainda que, em que pese vigore em nosso sistema judiciário o princípio do livre convencimento do Magistrado, o artigo 155 do Código de Processo Penal preleciona que não poderá o Juiz fundamentar decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Tal determinação legal existe para salvaguardar o acusado de eventuais abusos cometidos na fase inquisitorial que não podem ser verificados pela Defesa ou mesmo pelo Ministério Público, pois a prova foi produzida ao arrepio do contraditório judicial.

O mencionado dispositivo legal ao ser inserido no Código de Processo Penal, promoveu adequação ao princípio do devido processo legal, estampado na CF/88 (art. 5º, LV), protegendo o cidadão contra a ingerência arbitrária do Estado, proibindo a este exercer o seu direito de punir senão por meio de um processo judicial legítimo, concedendo ao acusado o direito de oferecer resistência, fiscalizar a produção de provas por meio de sua Defesa, produzir provas e influenciar, positivamente, no convencimento do Julgador.

Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução.

Nesse sentido, já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008270-54.2014.8.08.0024 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL APELADO: IRAN LEANDRO GURTNER RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 155 E 307, AMBOS DO CP. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. PROVA EXCLUSIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ARTIGO

155, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inquérito policial é peça de caráter inquisitivo, dispensável e com instrução provisória, e como tal, tem valor meramente informativo para a instrução da ação penal. Trata-se, assim, de sistema inquisitivo, sem contraditório e ampla defesa, sendo inadmissível fundamentar uma decisão condenatória em prova produzida exclusivamente naquela seara. Inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. 2. A manutenção da absolvição do apelado quanto ao crime de falsa identidade é medida que se impõe, porquanto inexistente qualquer prova judicializada que garanta a autoria do ilícito, posto que os elementos colhidos no inquérito policial não foram ratificados em juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminentíssimo Relator. (TJ-ES - APL: 00082705420148080024, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 20/07/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/07/2016) PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 155, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O princípio in dubio pro reo, decorrente da máxima constitucional da presunção de não culpabilidade, com previsão no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, veda condenações baseadas em conjecturas, sem a presença de provas contundentes da materialidade e da autoria delitivas, bem assim do dolo ou culpa do agente. 2. Não é viável uma condenação que tem como fundamento apenas a prova colhida na seara extrajudicial. Inexistindo elementos colhidos sob o crivo do contraditório aptos a reforçar a prova produzida extrajudicialmente, deve ser mantida a absolvição do réu devido à ausência de provas 3. Não se desincumbindo a acusação do ônus que lhe confere o artigo 156 do Código de Processo Penal, é de ser mantida a absolvição das rés, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 4. Apelação criminal improvida.(TRF-4 - ACR: 50012957320174047103 RS 5001295-73.2017.4.04.7103, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 29/05/2019, OITAVA TURMA) Por todo o exposto, sendo frágil e insipiente o conjunto probatório produzido em juízo, restando em desfavor dos réus o reconhecimento pessoal produzido exclusivamente em solo policial à revelia dos ditames do artigo 266 do Código de Processo Penal, inadmissível se mostra o decreto condenatório, tornando imperiosa a absolvição dos acusados, devendo vigorar o princípio do "in dubio pro reo".

Consequentemente, em razão da absolvição pelo delito de roubo, devem ser também absolvidos do crime estampado no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, e com fulcro no inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus MARCOS MATHEUS SANTOS FRANÇA e LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA, qualificados nos autos, dos crimes imputados na denúncia, tipificados no artigo art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações de praxe. Sem taxa judiciária, na espécie.

Ciência às partes.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

MARCOS VIEIRA DE MORAIS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA